

1501037-68.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI
Comarca: São Pedro
Foro: Foro de São Pedro
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... mesma senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DAS DROGAS. INTENSA PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501037-68.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501037-68.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE AMARAL DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos, etc.

LUAN HENRIQUE AMARAL DA SILVA e DANTON FABRICIO DE CAMPOS OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal, pois, segundo consta na denúncia, no dia 12 julho de 2022, por volta das 11h50min, na Rua Valentim Salomé Borba, altura do numeral 135, Jardim São Dimas, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela identidade de propósitos e unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico 29 [vinte e nove] eppendorfs contendo cocaína em seu interior [massa líquida de 4,4g]; e 160 [cento e sessenta] eppendorfs contendo cocaína na forma solidificada, vulgarmente conhecida como crack [massa líquida de 11,2g], drogas que causam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificados e citados, os acusados apresnetaram defesa preliminar [fls. 127/129 e 154/155].

Recebida a denúncia em 05/10/2022 [fls. 159/160].

Em audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se os inculpadados ao final do ato.

As partes apresentaram memoriais, substitutos dos debates orais.

Vieram os autos conclusos.

É, do necessário, o relatório.

Fundamento e decido.

De início, vale frisar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito da contenda.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão [fls. 12], pela fotografia [fls. 13], pelo laudo de constatação provisório do entorpecente [fls. 14/15] e, finalmente, pelo laudo de exame químico-toxicológico [fls. 64/66].

Quanto à autoria, o desfecho do caso mostra-se diverso em relação aos imputados.

No que tange ao incriminado Luan emerge a autoria indubitosa da prova colacionada, recaindo certa sobre ele, firmada que está na sua prisão em flagrante, assim como na palavra coerente e convincente das testemunhas ouvidas durante a persecução penal.

Em relação ao imputado Danton, por seu turno, em que pese haver nos autos indícios veementes de que estava agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços com o outro acusado, tenho que não se mostram os elementos de convencimento constantes nos autos suficientemente robustos para a condenação do réu.

Senão vejamos.

O réu LUAN HENRIQUE DO AMARAL DA SILVA, na fase inquisitorial, permaneceu em silêncio.

Em pretório, disse que estava subindo a rua de sua casa, quando foi abordado. Revistado, nada de ilícito foi encontrado. Os armígeros procuram algo no palco dos acontecimentos, mas não encontraram nada. Foi levado para a Delegacia e lá viu que Danton também foi preso e que os armígeros apresentaram drogas. Estava sozinho na rua, sem a presença de mais ninguém. Conhece Danton da localidade. Não é usuário de estupefacientes. Costuma ser abordado por policiais. Quando foi preso da vez anterior, foram outros policiais que o abordaram e em lugar diverso.

O réu DANTON FABRICIO DE CAMPOS OLIVEIRA, na fase administrativa, alegou que, na data dos fatos, foi até a residência do seu vizinho Luan para "bater papo". Relatou que, ao chegar, avistou uma viatura da Polícia Militar se aproximando. Narrou que seu colega empreendeu fuga ao avistar a viatura, quando fez o mesmo. Negou a prática do ilícito. Disse que não sabia que Luan carregava drogas consigo. Aduziu que havia acabado de chegar e não tiveram tempo de conversar antes da abordagem. Declarou que foi preso em flagrante no dia 21/07/2022 por tráfico de drogas e foi decretada sua liberdade provisória no dia 21/07/2022.

Em juízo, disse que trabalha com seu irmão e também realiza outros serviços. Não estava traficando. Aduziu que fugiu por medo, pois fora ameaçado pelos policiais em outra oportunidade. Disse que, em outra oportunidade, os policiais realizaram disparo de arma de fogo em sua direção. Era no horário do almoço quando dos fatos, razão pela qual estava em sua residência. No dia dos fatos, estava fumando, quando viu a viatura. Assustou-se e fugiu. Luan estava um pouco mais adiante. É usuário de maconha. Pede para um amigo buscar drogas, pois tem medo de ir ao ponto de venda de drogas e ser preso.

As teses exculpatórias do incriminado Luan não resistem quando confrontadas com o restante da globalidade probatória, esta, aliás, reitera-se, que é por demais incriminatória, segura ao édito condenatório pretendido pelo Órgão de Persecução Penal.

Por seu turno, a versão apresentada pelo outro inculcado – Danton –, em que pese não tenha sido totalmente comprovada de maneira contundente nos autos, apresenta alguma verosimilhança, suficiente para impor dúvidas razoável acerca de sua participação na ação antijurídica.

As testemunhas Anderson Bregantim Júnior e Cássio Manoel dos Santos, nas duas fases da ausculta, afirmaram que são Policiais Militares e, na data dos fatos, estavam realizando patrulhamento ostensivo de rotina. Ao chegarem na Rua Valentim Salomé Borba, lugar onde ocorre o ilícito comércio de entorpecentes, avistaram Dánton e Luan, conhecidos nos meios policiais por seus antecedentes. Ao ver a guarnição,

seguiram narrando, os imputados empreenderam fuga. O Policial Militar Cássio desembarcou da viatura e seguiu o increpado Luan, enquanto o Policial Militar Anderson seguiu o denunciado Danton. No entanto, segundo aduziram, o réu Danton conseguiu fugir. Alegaram que o increpado Luan foi abordado. Em revista pessoal, localizaram três eppendorfs contendo cocaína, e três eppendorfs contendo cocaína na forma solidificada. Ao ser questionado, o acusado confessou que estava praticando o comércio espúrio no local porque está desempregado. Retornaram ao local inicial, onde o implicado preso foi visto, e passaram a vistoriar o local, encontrando uma sacola plástica contendo em seu interior 157 [cento e cinquenta e sete] eppenfors contendo cocaína. O increpado assumiu a propriedade das drogas. Aduziram que, ao questionarem o incriminado preso acerca do implicado que se evadiu, foram informados que ele também estava no local praticando chatinagem. Em juízo, a testemunha Cássio afirmou, ainda, que receberam denúncia apócrifa no disque denúncia, apontando que no local estava sendo realizado o tráfico de drogas, apontando as características dos chatins. Chegando ao local, visualizaram os implicados com as mesmas características apontadas na delação anônima. Em juízo, a testemunha Anderson, afirmou que nada tem acerca do imputado Danton, tampouco que tenha qualquer coisa contra ele. Um disque denúncia deu conta de que estava sendo praticada a chatinagem no local dos fatos. Foram ao local e visualizaram Danton e Luan. Os inculpadados empreenderam fuga, mas apenas Danton logrou êxito em escapar. Afirmou que Danton já empreendeu fuga do local em outras oportunidades, inclusive mora perto do local. Segundo alegou, o imputado Danton, sempre que visualiza a viatura, empreende fuga. Aduziu que Luan confessou que esta realizando a chatinagem. Asseriu que, de regra, no local, os chatins atuam em mais de uma pessoa, um com olheiro. Novamente destacou que o local é ponto de venda de drogas e que, via de regra, os agentes atuam em conjunto, em mais de um chatim. Chegaram a atuar em 4 ou 5 pessoas.

Ainda no ponto, calha destacar, que o fato de ser agente de segurança pública não retira a credibilidade das informações trazidas pela testemunha. A condição funcional da testemunha não é causa de impedimento para ser ouvida como tal. Ademais, não há qualquer indício de que tenham motivos para imputar graciosamente os fatos aos réus. Nem mesmo indício, aliás, veio aos autos de que os agentes dos estados tivessem algum motivo ou tenham agido de forma ilegal em relação aos inculpadados. E o fato de os ter abordado anteriormente, na verdade, reforça a ideia que não estão agindo com parcialidade, pois, do contrário, já teriam realizado a prisão dos réus nas outras oportunidades.

Portanto, seus relatos são aptos à construção do convencimento e encontram-se em consonância com o restante das provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido. E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROVA. Depoimento policial Valor Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido neste aspecto" (TJSP Apelação Criminal nº 993.08.043553-7 São Paulo 16ª Câmara de Direito Criminal Relator Newton Neves 09.09.2008 v.u.).

Na mesma senda, C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando

corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

IV - Afastar a condenação com base na nulidade da instrução, em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feitas pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

V - Repiso, que seria necessário aprofundado reexame do conjunto fático probatório a análise da tese de que o paciente faria jus a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, constante do do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo inviável sua análise em razão dos limites impostos à via mandamental.

VI - Consoante ficou assentado na decisão agravada, o quantum de pena aplicado (6 anos de reclusão), o regime poderia, em princípio, ser o semiaberto. Todavia, não se pode olvidar a existência de circunstâncias desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na terceira fase, para afastar a causa especial de redução de pena. Assim, inviável a fixação do regime intermediário (semiaberto) unicamente em razão do montante de pena imposto ao paciente, ex vi dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006.

VII - Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda encontra-se estabelecida acima do patamar prevista para o deferimento da benesse (6 anos de reclusão), nos termos do art. 44 do Código Penal. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (original sem grifo)

Nessa esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

A testemunha Edis Pedro da Silva, em pretório, asseriu que reside em frente a residência do imputado. É dono de um bar em frente à residência do inculcado Danton. Vê o inculcado sempre saindo para trabalhar com seu irmão. Ao que sabe, o denunciado fuma maconha. Já presenciou policial efetuar disparo de arma de fogo nas cercanias. Presenciou o implicado sendo preso em outra oportunidade, quando houve disparo de arma de fogo. Disse que é tratado como bandido por policiais. Nas cercanias há ponto de venda de drogas. Asseriu que conhece o inculcado Luan. Ao que sabe, Luan trabalha com a sua família.

Por fim, na condição de testemunha, Maria das Graças da Silva, em juízo, afirmou que é amiga do imputado Danton e que o conhece há muitos anos. Não presenciou os acontecimentos. Não possui conhecimento se o imputado pratica o tráfico de drogas. Asseriu que o inculcado trabalha de servente de pedreiro. Dáton é usuário de maconha. Disse que o imputado reside na Rua Valetim Salomé Borges, 2049.

Em relação ao réu Danton, portanto, a prova dos autos não se mostra suficientemente robusta à prolação de édito condenatório, havendo dúvida razoável quanto ao contexto no qual fora ele flagrado no palco dos acontecimentos.

O acusado é usuário de estupefacientes, o que não é causa de exclusão do crime mas, diante das circunstâncias do caso concreto, justificam que estava no local dos fatos quando da chegada dos policiais. Também justifica em tese sua presença a

situação de residir próximo ao palco dos acontecimentos. Chama atenção também o horário da abordagem, muito próximo do horário de almoço, o que corrobora as alegações das testemunhas apontando que trabalha lícitamente e a tese de que estava nas cercanias por ser horário de almoço.

Ainda, o imputado não foi preso em flagrante e, mesmo se evadindo, não foi relatado pelas testemunhas presenciais dos fatos que o ele se livrou de qualquer objeto durante a fuga. Também não relataram os armígeros que o inculpafo fora flagrado em ato que indicasse o comércio espúrio.

Por fim, a denúncia apócrifa relatada pelos armígeros, por mais que seja um importante e contundente elemento de convencimento, no caso do implicado, em virtude do exposto adrede, não pode servir sozinha para sua condenação.

Verifica-se, portanto, que a prova oral amealhada ao feito não permite afirmar, com a segurança necessária, que o imputado Danton estava realmente realizando a chatinagem no local.

E não se está duvidando da palavra dos policiais. Conforme já afirmado supra, seus relatos foram firmes e não há qualquer indício de que tenham qualquer motivo para parcialidade ou para cometer delitos em face dos incriminados. Inclusive, se realmente quisessem incriminar o denunciado, teriam relatado outras circunstâncias envolvendo sua conduta, não deixariam margem para sua absolvição.

Também não se nega que o tráfico não exige dedicação integral e usuários costumam traficar para manter o vício, entretanto, as demais peculiaridades do caso em liça apontam tais elementos – ser o réu usuário e possuir emprego lícito – como fatores que corroboram as versões defensivas.

Diante dessa conjuntura, não havendo elementos de convicção suficientes que indiquem que o acusado Danton praticou o tráfico de drogas descrito na inicial acusatória, inviável se mostra a sua condenação.

Ante o exposto, em sendo precária a prova amealhada a possibilitar a prolação de um édito condenatório, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, julgando-se improcedente a pretensão punitiva estatal em relação ao acusado Danton. Diverso é o desfecho no tocante ao denunciado Luan.

Ainda que o réu tenha negado a prática do crime a ele imputado, sua versão encontra-se completamente isolada das demais provas amealhadas aos autos.

Verifica-se dos elementos de convencimento corporificados aos autos que os agentes do estado foram até o palco dos acontecimentos, conhecido como ponto de comércio espúrio, verificar denúncia apócrifa que apontava inclusive as características das pessoas que estavam cometendo tal crime. Ao chegar no local apontado pelo delator, visualizaram duas pessoas com as mesas características. Ao perceber a presença da guarnição, os imputados empreenderam fuga, Danton logrando êxito em se evadir e Luan não. Este, extrajudicialmente, informou aos armígeros que ambos estavam na prática da chatinagem. Com o acusado preso em flagrante – Luan – foram encontrados estupefacientes de natureza diversa. No local onde estava o acusado, os armígeros encontraram mais drogas, idênticas às que estavam juntou ao corpo do acusado Luan, inclusive, embalados da mesma forma [fl. 13].

Mas não é só.

A prova amealhada ao processo também indica que o imputado era conhecido nos meios policiais pela prática da chatinagem, o que também é confirmado pela prova documental das folhas 30. Também chama atenção que o documento da folha 30 aponta que o inculpafo Luan foi preso em flagrante pelo mesmo delito em 30/08/2021 [processo nº 1501364-47.2021.8.26.0599].

Destarte, tem-se que os elementos de prova contidos nos autos são por demais contundentes quanto à autoria, não sobejando dúvidas de que o incriminado – Luan –, trazia consigo e guardava drogas para posterior venda a terceiros, subsumindo-se sua conduta, portanto, ao tipo penal incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/06, crime, aliás, equiparado a hediondo [artigo 2º da Lei nº 8.072/90].

Ademais, o local conhecido como ponto de comércio espúrio, a forma como estavam acondicionados os estupefacientes, a sua natureza variada, bem como sua quantidade e a vida anteacta do inculpafo são também fatores que indicam que os alucinógenos se destinavam à prática da chatinagem [artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06].

Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal como composto o tipo penal com

inúmeras condutas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia.

Deveras, “é desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12, da Lei nº 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev nº 261.898-3/2, rel. Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel. Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639, 594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3.132).

Na realidade, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” [VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151, grifei]. O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização [STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer].

De rigor, pois, a condenação.

Como tese de defesa pessoal, o increpado alega a ocorrência de flagrante forjado. A tese também não merece acolhida.

A alegação de flagrante forjado é a mais comum em processos criminais, versão natural de quem pode se valer de, praticamente, todos os meios na tentativa de escusar-se da responsabilidade penal resultante de suas ações.

Entretanto, mesmo no processo penal, onde vigoram princípios como o do in dubio pro reo, exige-se a comprovação mínima das teses ventiladas pela defesa e pelos réus, pois há também uma divisão do ônus da prova [artigo 156 do CPP].

E na hipótese vertente, a tese de flagrante simulado não veio respaldada por qualquer tipo de prova produzida pela defesa, seja oral ou testemunhal, que, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 156 do CPP. Ademais, não crível acreditar que agentes de segurança pública andem pelas ruas na posse de grande quantidade de entorpecentes, de natureza variada para imputar graciosamente crimes a cidadãos que sequer sabem se irão encontrar.

Não há falar, portanto, em flagrante forjado.

Ainda em relação à tese de defesa pessoal do acusado de flagrante forjado, tal conduta demonstra sua personalidade propensa ao cometimento de ilícitos, pois compareceu em Juízo e, muito além do direito ao silêncio, mentiu na Casa da Justiça, imputando aos policiais a prática de crime, apenas para tentar se esgueirar das consequências de seus atos.

É certo que “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”.

Diante desse quadro, na primeira fase do processo dosimétrico, as incoativas impostas ao inculcado serão elevadas, pois demonstrou com sua conduta que possui personalidade propensa ao cometimento de ilícitos, sequer contendo seu ímpeto na Casa da Justiça.

Em relação ao fato de o inculcado possuir trabalho lícito, em nada altera o deslinde do feito, pois o tráfico não exige dedicação em tempo integral para ser perpetrado.

No tocante ao fato de parte dos entorpecentes apreendidos não terem sido encontrados em poder do inculcado, mas próximo dele, não se pode ignorar que as

organizações criminosas, especializadas no cometimento de crimes previstos na Lei nº 11.343/06, funcionam como uma empresa, cada vez mais especializadas e organizadas, agindo sempre com o objetivo de obter o maior lucro possível e reduzir ao máximo as possibilidades de perdas. Logo, é natural, e é o que se observa ordinariamente em delitos dessa natureza, que o chatim não leve consigo grande quantidade de entorpecentes, guardando a maior parte da substância ilícita em local próximo, sempre tentando evitar grandes prejuízos e a configuração do crime insculpido no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Malgrado a primariedade do inculpinado, restou bem evidenciado nos autos que se dedica a atividades criminosas, notadamente listadas como crime na Lei nº 11.343/06.

As testemunhas presenciais dos fatos destacaram que o imputado era conhecido nos meios policiais. A vida pregressa do acusado [folha 30] aponta que foi preso após ser flagrado em 30/08/2021 pela prática do crime de tráfico de drogas, processo ao qual responde em liberdade.

Esse quadro aponta que o inculpinado se dedica a atividades criminosas listadas na Lei nº 11.343/06.

Mas não é só. Outros elementos de convencimento reforçam tal conclusão.

A excessiva quantidade 180 porções de drogas, variedade e naturezas diversas [29 porções de cocaína e 160 porções de crack] dos entorpecentes apreendidos com o inculpinado, a forma como estavam acondicionados, o horário que estava o réu perpetrando a chatinagem [11 horas e 50 minutos], a ausência total de provas nos autos de que exerce atividade laboral lícita, mesmo que informal, são circunstâncias que também impedem a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que evidenciam que o réu não pratica essa espécie de crime ocasionalmente, mas, ao contrário, está envolvido com atividades criminosas, circunstância que, inclusive, também se extrai, conforme exarado adrede, do restante do caderno probatório.

Sobre o tema, vale referir trecho do decidido pelo C. STJ:

(...) Assim, interpretando o dispositivo legal em comento, esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado, bem como a sua natureza, constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais (...) (REsp n. 1.344.604/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 19.12.2013).

Na mesma senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DAS DROGAS. INTENSA PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica à atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem.

2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual intenso envolvimento do réu com a atividade do tráfico, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

3. Em que pese a menção à hediondez do delito, correta a imposição do regime

fechado, ante a circunstância desfavorável da quantidade/natureza das drogas valorada na terceira fase, a teor dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 621.370/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

As circunstâncias da prisão do imputado denotam que não era ele "causal mercador" de estupefacientes. De certo que a neófito não seria confiada tal quantidade e variedade de entorpecentes, estes que, aliás, para serem comercializados, também dependeriam de certa dedicação e empenho, pelo acusado ou por outros assecclas ignotos, atingindo considerável número de usuários.

Visa a Lei, não se pode ignorar, dentro outros objetivos, atingir com a benesse do § 4º do artigo 33, o chatin não eventual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder apresenta-se capaz de atingir pequeno número de usuários, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas.

Assim, as peculiaridades do caso em liça, suso mencionadas, não autorizam a aplicação da minorante, sob pena, inclusive, de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo legal.

Consigno, ainda no ponto, que a quantidade de droga apreendida com o inculminado, mesmo sendo utilizada também para afastar ao privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, poderá ser sopesada negativamente na primeira fase do processo dosimétrico, sem que isso consista em bis in idem, conforme se infere da jurisprudência do C. STF, in verbis:

(...) a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa não configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no AREn. 666.334(Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" [ARE 666.334/RG, Rel. Min.: Gilmar Mendes; DJ de 6/5/2014]" [HC nº 370.057 RO; Rel. Min. Joel Ilanpaciornik; j. 01.12.16].

Ademais, reitera-se, a quantidade e variedade de estupefacientes, mesmo que ignorada, em nada alteraria o deslinde do feito no ponto, porquanto, reitera-se, os demais elementos de prova constantes nos autos apontam que o inculcado se dedica com assiduidade ao comércio antijurídico de drogas.

Diante de todo o exposto, a absolvição é meta impossível de ser alcançada quanto ao delito em questão, inclusive por não haver nos autos qualquer causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, sendo totalmente imputável.

Passo a dosar as penas do Réu Luan

1ª fase – circunstâncias judiciais [artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06]

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, excede o ordinário. O inculcado estava em liberdade provisória concedida em ouro feito – processo nº 1501364-47.2021.8.26.0599 [fl. 30] – o que torna sua conduta ainda mais reprovável, pois seu dever de não cometer delitos era ainda mais acentuado em virtude da sua condição no outro feito.

O acusado não registra antecedentes.

A conduta social do implicado não foi desabonada.

O inculminado demonstra personalidade propensa ao cometimento do ilícito, pois, nos termos da fundamentação supra, nem mesmo o fato de estar na Casa da Justiça impediu que seguisse com seu ímpeto de cometer atos ilícitos.

Os motivos do crime são inerentes à espécie, lucro fácil às expensas da saúde pública.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, tendo em vista a

natureza variada dos estupefacientes encontrados em poder do acusado e as características delas – cocaína e crack –, de elevado poder viciante e destrutivo. No ponto, consigno que a natureza dos entorpecentes devem ser valorados nesta fase do processo dosimétrico por expressa previsão legal [artigo 42 da Lei nº 11.343/06]. Além disso, desconsiderar a natureza dos entorpecentes, quando destoem do que ordinariamente se verifica em casos análogos, é negar vigência à norma mencionada supra, bem como aos princípios constitucionais da individualização da pena e da isonomia, pois se estaria dispensando tratamento idêntico aos que comercializam estupefacientes de menor potencial lesivo à saúde pública e se encontram na posse de pequena quantidade de drogas, aos que vendem entorpecentes de elevado poder viciante e destrutivo e foram flagrados na propriedade de grande quantidade de drogas. Em última análise, a quantidade e a natureza das drogas deve ser sopesada neste vetor, porquanto eleva em muito o desvalor da ação perpetrada pelo inculpatado, obedecendo-se, assim, expressa disposição de lei. Mas não é só. O inculpatado estava praticando a chatinagem em plena via pública, em dia de semana [terça-feira] e em plena luz do dia, demonstrando destemor e ousadia.

As consequências do fato não destoaram das normais ao ilícito.

Não há comportamento da vítima a ser considerado, pois se trata de crime que atinge toda a coletividade.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 7 [sete] anos de reclusão e 700 [setecentos] dias-multa, sanções que vão definitivadas em virtude de não incidirem ao caso em liça circunstâncias legais.

Quanto à razão unitária de cada dia-multa, tendo em vista a condição econômica do implicado, fixo-a em 1/30 [um trigésimo] do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, em observância ao que preceitua o artigo 33, da Lei nº 11.343/06, considerando as operadoras do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, analisadas na primeira fase da individualização da pena, especialmente as vetoriais culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, mostrando-se o regime fixado o único adequado à necessária reprovação e prevenção do ilícito penal, que se mostrou grave no caso concreto, também em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas com os inculpatados [AgRg no HC 621.370/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021].

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF – HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo leciona Cezar Roberto Bittencourt, “quando aqueles três fatores [art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas] não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado [necessário e suficiente] para aquele caso concreto e para aquele apenado [art. 33, § 3º, do CP]” [Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 12 ed. São Paulo: Saraiva 2008, p. 450].

Ademais, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena [cf. HC. n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012].

Inviável a aplicação das benesses do artigo 44 ou do artigo 77 do CP em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do quantitativo punitivo aplicado.

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial acusatória, razão pela qual:

A] CONDENO LUAN HENRIQUE AMARAL DA SILVA à pena de reclusão pelo período de 7 [sete] anos, em regime inicial FECHADO, e 700 [setecentos] dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso

nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 2º da Lei nº 8.072/90.

B] ABSOLVO, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, o acusado DANTON FABRICIO DE CAMPOS OLIVEIRA da imputação que lhe é dirigida na denúncia, por incursão nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por ter o implicado Danton respondido em liberdade ao processo, bem como em virtude do desfecho em relação a ele, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Ao contrário, o implicado Luan foi preso em flagrante, cometeu delito equiparado e hediondo enquanto em liberdade provisória, benesse concedida em processo pela prática de idêntico delito. Não bastasse, foi preso em plena via pública e luz do dia com relevante quantidade de drogas, ambas de elevado poder viciante e destrutivo. Assim, agora com base em juízo de certeza da culpa, a manutenção da prisão do sentenciado como forma de garantir a ordem pública e paz social é medida impositiva.

Custas pelo acusado Luan.

Expeça-se o PEC provisório, adequando-se ao regime fixado ao imputado Luan.

Recomendo o condenado à unidade prisional em que se encontra.

Se o caso, oportunamente, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Após o trânsito em julgado da sentença, se mantida a condenação, procedam-se às anotações de estilo, com o lançamento do nome do réu no rol de culpados, formação do PEC definitivo e posterior remessa à VEC, oficiando-se ao TRE.

Destruam-se as substâncias entorpecentes, nos termos do artigo 52-A e artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Declaro o perdimento dos bens ilícitos encontrados em poder do imputado condenado [artigo 243, parágrafo único, da Carta da República].

P.R.I.

São Pedro, data certificada digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA